

Nur Rabecca Al-Islam binti Abdullah
lawan
Mohd Farhan Bin Jamaludin



Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel)

31 Mei 2022 / 29 Syawal 1443H

Kes Semakan No. 10000-003-0008-2022

[Permohonan Semakan di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon : *Mohamad Zulfahmi bin Yaamat dari Tetuan Aniza Ammar & Associates*

Peguam Responden : *Tiada*

ALASAN PENGHAKIMAN

Fakta Kes

1. Pemohon telah memohon semakan kes kepada Mahkamah Rayuan Syariah Selangor berhubung keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam Selangor bertarikh 18 Februari 2021 bagi Permohonan No: 10207-038-0603-2020.
2. Pemohon memohon kepada Mahkamah Rayuan ini sepertimana berikut:-

- i. Mahkamah menyemak dan mengubah keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam Selangor bertarikh 18 Februari 2021 berdasarkan peruntukkan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003
 - ii. Mahkamah memerintahkan hak jagaan anak sementara ke atas lima anak yang bernama Muhammad Firdaus Umpong bin Abdul Jabbar (No. Mykid: 060218-13-0495), Muhammad Firman Runtang bin Abdul Jabbar (No Mykid: 080514-13-0877), Muhammad Fahman Hakim bin Abdul Jabbar (No Mykid: 150807-14-1475), Muhammad Iman Fakhruallah bin Mohd Farhan (No Mykid: 150807-14-0535), Muhammad Rafi Fathuddin bin Mohd Farhan (No Mykid: 170112-10-2127) diserahkan kepada Pemohon selaku ibu kandung sehingga kes induk no 10207-028-0227-2020 diputuskan.
3. Pemohon dan Responden telah disabitkan penceraian oleh Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat, Selangor pada 11 Mac 2020.
4. Pemohon dan Responden telah dikurniakan tiga (3) orang cahaya mata iaitu seorang anak tidak sah taraf dan dua orang anak sah taraf iaitu :-
 - i. Muhammad Fahman Hakim bin Abdul Jabbar (No Mykid: 150807-14-1475) [anak tak sah taraf]

- ii. Muhammad Iman Fakhrullah bin Mohd Farhan (No Mykid: 150807-14-0535) [anak sah taraf],
 - iii. Muhammad Rafi Fathuddin bin Mohd Farhan (No Mykid: 170112-10-2127) [anak sah taraf]
5. Pemohon sebelum bernikah dengan Responden telah mempunyai dua orang anak lelaki hasil daripada perkahwinan yang terdahulu iaitu sebagaimana berikut:
- i. Muhammad Firdaus Umpong bin Abdul Jabbar (No. Mykid: 060218-13-0495),
 - ii. Muhammad Firman Runtang bin Abdul Jabbar (No Mykid: 080514-13-0877),
6. Pada tarikh 25 Ogos 2020, Responden telah memfailkan Notis Permohonan untuk mendapatkan Perintah Interim Hadhanah (secara Inter-parte) di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor melalui Permohonan No: 10207-038-0603-2020 bagi mendapatkan hak jagaan sementara terhadap kelima-lima orang anak tersebut.
7. Pada 18 Februari 2021, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah mengeluarkan perintah dengan menyerahkan hak jagaan sementara semua anak tersebut kepada Responden sehingga kes induk hak jagaan anak melalui Saman No: 10207-028-0227-2020 diputuskan atas alasan mengekalkan status quo jagaan anak-anak tersebut.

8. Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 18 Februari 2021 telah memutuskan seperti berikut:-

- i. Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon berdasarkan seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
- ii. Mahkamah memerintahkan bahawa Hak Jagaan Sementara ke atas anak-anak yang bernama sebagaimana berikut:
 - a. Muhammad Firdaus Umpong bin Abdul Jabbar (No. Mykid: 060218-13-0495),
 - b. Muhammad Firman Runtang bin Abdul Jabbar (No Mykid: 080514-13-0877),
 - c. Muhammad Fahman Hakim bin Abdul Jabbar (No Mykid: 150807-14-1475)
 - d. Muhammad Iman Fakhruallah bin Mohd Farhan (No Mykid: 150807-14-0535)
 - e. Muhammad Rafi Fathuddin bin Mohd Farhan (No Mykid: 170112-10-2127)

hendaklah diberikan kepada Pemohon sehingga kes induk hak jagaan anak melalui Saman No: 10207-028-0227-2020 diputuskan

- iii. Mahkamah memerintahkan bahawa Responden diberikan hak lawatan dan bersama dengan anak-anak tersebut pada bila-bila masa yang munasabah dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada Pemohon.

- iv. Mahkamah memerintahkan Responden hendaklah diberikan hak bermalam dengan anak-anak tersebut pada minggu kedua dan keempat dengan mengambil anak-anak tersebut bermula jam 9.00 pagi hari Sabtu dan memulangkan semula anak-anak tersebut kepada Pemohon sebelum atau pada jam 6.00 petang hari Ahad.
 - v. Pengambilan dan pemulangan anak-anak adalah di alamat tempat tinggal anak-anak tersebut atau tempat lain di atas persetujuan pihak-pihak.
 - vi. Mahkamah memerintahkan supaya mana-mana pihak ketiga termasuk badan-badan kerajaan iaitu secara khususnya tetapi tidak terhad kepada Jabatan Imigresen Malaysia, Polis Diraja Malaysia (PDRM), badan-badan berkanun dan/atau mana-mana pihak berkuasa yang lain hendaklah memberikan kerjasama dalam melaksanakan Perintah Mahkamah ini.
 - vii. Sebarang kegagalan mematuhi Perintah ini adalah melakukan suatu penghinaan kepada Mahkamah dan dengan itu boleh dikomitkan ke penjara.
9. Pemohon tidak berpuashati dengan terma Perintah Interim Hak Penjagaan Anak tersebut dan telah membuat Permohonan Semakan Kes ke Mahkamah Rayuan Syariah Selangor pada 7 Februari 2022 melalui Permohonan Semakan No: 10000-003-0008-2022.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

10. Sebelum Kami mengulas permohonan Pemohon, Kami menegaskan bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Akta/Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah bertujuan untuk menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa remidi atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.
11. Selain daripada Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 bertajuk "*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*," yang telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Syariah telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja antaranya ialah keputusan Panel Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes ***Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah [2013] JH36(2)***, kes ***Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid***, kes mal (semakan) no. 14000-003-0033-2012, kes ***Khadrishah bin Khalid lwn. Fadhilah binti Othman***, kes mal (Semakan) no. 10000-003-0009-2011 dan kes ***Adi Asri b.***

Baharom lwn. Andini Nidia Putra, kes mal (Semakan) no. 10000-003-0015-2012.

12. Berdasarkan kepada otoriti dan panduan kes-kes di atas maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah/penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan hukum syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.
13. Kami dapati bahawa kes ini adalah permohonan semakan bagi kes interim *inter-parte* yang mana terdapat pengecualian kes-kes interim *inter-parte* ini boleh disemak iaitu apabila ternyata berlaku salah aturan yang menjejaskan keadilan atau sesuatu keputusan tersebut menyalahi hukum syarak yang bersifat *qatie* (muktamad) dan/atau peruntukkan undang-undang, sebagaimana kes **Mohd Fauzi bin Yaacoob lwn. Zabedah binti Hanapiah** kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0009-2010 yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Selangor pada 20-9-2010 (belum dilaporkan) dan kes **Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah**, Kes Mal (Semakan) No.14000-003-0035-2011 yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan pada 07/03/2012 yang menyatakan seperti berikut:

"Proses semakan semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan

yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qat'ie atau jelas berlawanan dengan Undang-undang yang sedang berkuatkuasa."

14. Sebelum kami mengulas lanjut berhubung dengan permohonan Pemohon, kami dapati bahawa anak yang menjadi isu pertikaian di antara Pemohon dan Responden ialah dua (2) orang anak hasil pernikahan Pemohon yang terdahulu, seorang (1) anak tidak sah taraf hasil hubungan Pemohon dan Responden dan dua (2) orang anak hasil pernikahan Pemohon dan Responden. Anak-anak tersebut lelaki kesemuanya dan kini berumur diantara 7 hingga 14 tahun.
15. Penjagaan anak apabila bercerainya pasangan suami isteri adalah lebih berhak kepada ibunya dengan merujuk kepada hadith Nabi s.a.w

عن عبد الله بن عمرو أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وحجري له حواء ، وثدي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم " انت احق به ما لم تنزوي "

Bermaksud:

Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar Ibnu 'As mengenai seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya dan ia mempunyai seorang anak lelaki, suaminya pula hendak mengambil anak itu untuk di peliharanya dan dijaganya. Maka perempuan tersebut

telah datang menemui Rasulullah seraya berkata: Wahai Rasulullah, bahawasanya anakku ini perutku yang mengandungnya, asuhankulah yang mengawasinya, air susu akulah minumannya, ayahnya hendak mengambilnya daripadaku.

Maka Sabda Rasulullah s.aw : Engkaulah yang lebih berhak menjaga anak itu selama engkau belum berkahwin

(Riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud)

16. Kami merujuk Kitab al Umm yang dikarang oleh al-Imam al-Shafie, jilid 3, Beyrut, Lebanon menyebutkan:-

فاذا افترق الأبوان وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها مالم تتزوج وماكانوا صغارا فاذا بلغ أحدهم سبعا أو ثمانا سنين وهو يعقل خير بين أبيه وأمه وكان عند أيهما اختار

Maksudnya:

“Apabila berpisah kedua ibu bapa dan kedua-duanya berada dalam satu qariah maka ibu adalah lebih berhak terhadap anaknya selama ia belum berkahwin lain dan semasa anak-anak itu masih kecil. Apabila genap umur mereka tujuh tahun atau lapan tahun dan ia sempurna akal ia disuruh pilih di antara bapa dan ibunya dan ia akan bersama dengan siapa yang dipilih.” (Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin idris , Al-Umm, Juzuk 5 m.s. 99)

17. Manakala isu penjagaan anak tak sah taraf adalah lebih berhak kepada ibu yang melahirkan telah dibahaskan di dalam كتاب موقع محمد صالح المنجد, Jilid 5 halaman 7070 sebagaimana berikut:

إلحاق ولد الزنا بأمه

f-[كنت أقرأ في موقعك وممر بي شيء لا أراه معقولا. تحت عنوان (التوبة) والوضع الشرعي الطفل. كتب المؤلف (الشيخ) بأنه ليس من مسئولية والد الطفل (الزاني) (أن يربي أو يرعى الطفل بأي شكل من الأشكال وأن العبء يقع على الأم

18. Malah, hak penjagaan anak tidak sah taraf ini telah diperuntukkan oleh undang-undang dalam seksyen 86 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan hak jagaan anak tak sah taraf adalah eksklusif kepada ibu yang melahirkan dan saudara mara ibu sebagaimana berikut:

Seksyen 86. Penjagaan anak-anak tak sahtaraf

Penjagaan kanak-kanak tak sahtaraf adalah semata-mata pada ibu dan saudara mara ibu.

Oleh itu, anak tidak sah taraf ini adalah hak sepenuhnya ibu kandung dan saudara mara ibu yang mana hanya mereka yang boleh menjaga anak tak sah taraf tersebut.

19. Kami merujuk kepada Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-57 ("Muzakarah Fatwa Kebangsaan") pada 10 Jun 2003 telah membincangkan mengenai Anak Tak Sah Taraf dan memutuskan seperti berikut:

- a. *Anak Tak Sah Taraf ialah anak yang dilahirkan di luar nikah sama ada akibat zina atau rogol dan dia bukan daripada persetubuhan syubhah atau bukan daripada anak perhambaan.*
- b. *Anak dilahirkan kurang dari 6 bulan 2 lahzah (saat) mengikut Takwim Qamariah daripada tarikh tamkin (setubuh).*

Anak tak sah taraf tidak boleh dinasabkan kepada lelaki yang menyebabkan kelahirannya atau kepada sesiapa yang mengaku menjadi bapa kepada anak tersebut. Oleh itu mereka tidak boleh pusaka mempusakai, tidak menjadi mahram dan tidak boleh menjadi wali.

20. Seterusnya, Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor turut memutuskan hal yang sama dalam keputusan Muzakarah Fatwa Negeri Selangor pada 17 Januari 2005 yang telah diwartakan pada 28 April 2005. Keputusan muzakarah tersebut adalah seperti berikut:-

1. *Anak yang dilahirkan tanpa nikah sama ada hasil daripada zina, rogol atau melalui cara saintifik yang bertentangan dengan hukum syara'.*
2. *Anak yang dilahirkan kurang daripada 6 bulan 2 lahzah qamariah dari waktu 'Imkan ad Dukhul' dan bukan hasil daripada persetubuhan syubhat.*
3. *Anak yang dilahirkan lebih daripada 6 bulan 2 lahzah qamariah dari waktu 'Imkan ad Dukhul' selepas akad yang sah dan ada bukti dari segi syara' bahawa anak tersebut ialah*

anak tanpa nikah melalui iqrar (pengakuan) mereka yang berkenaan (suami dan isteri tersebut atau salah seorang daripadanya), atau 4 orang saksi yang memenuhi syarat-syarat mengikut hukum syara'.

21. Berbalik kepada kes yang dipohon, setelah meneliti permohonan dan affidavit Pemohon serta memanggil rekod perbicaraan Kes Mal No. 10207-038-0603-2020, kami dapati Pemohon telah mempersoalkan keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah berkaitan penentuan interim hak jagaan bagi dua (2) orang anak hasil pernikahan Pemohon yang terdahulu kepada Responden sedangkan Responden tidak mempunyai locus dalam permohonan tersebut.
22. Pemohon juga mempertikaikan keputusan Hakim Bicara dalam memerintahkan interim hak jagaan kepada Responden atas alasan mengekalkan *status quo* jagaan yang sebenar. Hakim bicara dalam para 7 dan 8 Alasan Penghakiman menyatakan bahawa "*pertukaran hak jagaan anak-anak tersebut hendaklah dielakkan buat sementara waktu bagi mengelakkan kemudharatan..*". Pemohon menyatakan bahawa alasan penghakiman tersebut adalah sesuatu yang tidak munasabah kerana anak-anak tersebut lebih lama berada dalam jagaan Pemohon berbanding Responden.
23. Mahkamah dalam meneliti permohonan dan alasan penghakiman telah mendapati wujudnya kesalahaturan yang nyata, kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang *qatie* atau jelas berlawanan dengan Undang-undang yang sedang berkuatkuasa telah berlaku.

24. Perintah Hakim Bicara tersebut telah menyalahi hukum Syarak atau undang-undang apabila Hakim Bicara menetapkan hak jagaan sementara bagi dua orang anak hasil pernikahan Pemohon yang terdahulu dan seorang anak hasil perhubungan Pemohon dan Responden tanpa nikah diberikan kepada Responden.
25. Berdasarkan otoriti di atas, Kami bersepakat bahawa Pemohon adalah merupakan hadhin yang berhak dan layak dalam menjaga dua orang anak hasil perkahwinan terdahulu Pemohon. Mahkamah bersetuju bahawa Responden tidak mempunyai locus untuk menjaga dua orang anak tersebut kerana Responden adalah seorang bapa tiri dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan anak-anak tersebut.
26. Isu mengenai penasaban anak ini amat dititikberatkan dalam agama Islam. Malah, ia juga termasuk dalam salah satu *Maqasid al-Syariah* yang perlu dipelihara. Oleh yang demikian, merujuk kepada fatwa-fatwa tersebut, anak tidak sah taraf tidak boleh dinasabkan kepada bapa biologi. Seterusnya bagi hak jagaan anak bagi anak tidak sah taraf adalah sepenuhnya diberikan kepada ibu kandung dan saudara mara ibu kandung tersebut sahaja.
27. Kami berpandangan bahawa nasab merupakan salah satu fondasi dasar yang kukuh dalam menentukan hak jagaan. Oleh itu, kami bersetuju bahawa Responden bukan sahaja tidak mempunyai locus standi untuk memohon interim hak jagaan malah Responden juga tidak mempunyai locus untuk diberikan hak menjaga dua orang anak Pemohon hasil dari perkahwinan yang terdahulu dan seorang anak tak sah taraf hasil hubungan Responden dengan Pemohon.

Secara jelasnya, Responden tidak mempunyai hubungan nasab dengan anak-anak tersebut kecuali 2 orang anak hasil pernikahan Responden dengan Pemohon.

28. Oleh yang demikian, Mahkamah berpuashati bahawa Pemohon telah memberikan alasan syarak dan undang-undang berkenaan dakwaan berlakunya kekhilafan Hakim Bicara semasa memutuskan perintah interim tersebut.
29. Di peringkat ini, kami berpuashati bahawa kami telah menemui perintah yang menyalahi hukum Syarak dan undang-undang serta kecacatan atau salah aturan prosiding sepanjang kes tersebut berjalan yang menjejaskan keadilan. Oleh yang demikian, kami mempunyai apa-apa alasan untuk kami campurtangan serta mengakas perintah Kes Mal No. 10207-038-0603-2020 bertarikh 18 Februari 2021 tersebut.
30. Demi kebajikan anak-anak tersebut juga, kami menegaskan bahawa pertikaian antara Pemohon dan Responden di dalam kes induk perlulah disegerakan. Permohonan yang bersifat interlokutori selepas ini seboleh-bolehnya tidak digalakkan kerana ianya boleh melambatkan penyelesaian muktamad di dalam kes induk.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan Semakan Pemohon dan Afidavit Sokongan Pemohon, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Permohonan Semakan Pemohon adalah DITERIMA

2. Para 2 Penghakiman Permohonan No: 10207-038-0603-2020 dipinda kepada

a. Mahkamah memerintahkan Hak Jagaan Sementara ke atas anak- anak bernama sebagaimana berikut:

- i. Muhammad Firdaus Umpong bin Abdul Jabbar (No. Mykid: 060218-13-0495),
- ii. Muhammad Firman Runtang bin Abdul Jabbar (No Mykid: 080514-13-0877),
- iii. Muhammad Fahman Hakim bin Abdul Jabbar (No Mykid: 150807-14-1475)

hendaklah diberikan kepada Pemohon sehingga kes induk hak jagaan anak melalui Saman No: 10207-028-0227-2020 diputuskan.

b. Mahkamah memerintahkan Hak Jagaan Sementara ke atas anak- anak bernama sebagaimana berikut:

- i. Muhammad Iman Fakhruallah bin Mohd Farhan (No Mykid: 150807-14-0535)
- ii. Muhammad Rafi Fathuddin bin Mohd Farhan (No Mykid: 170112-10-2127)

hendaklah diberikan kepada Responden sehingga kes induk hak jagaan anak melalui Saman No: 10207-028-0227-2020 diputuskan

3. Para 1, 3, 4, 5, 6 dan 7 Penghakiman Permohonan No: 10207-038-0603-2020 adalah dikekalkan.

Penghakiman ini diberikan oleh:-



1. YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh:-



2. YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh:-



3. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selango